

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Princípios Modernos de Direito Penal

Essa aula é de muita teoria. É aquele assunto cheio de “fala difícil”, cheio de teses, tudo amplo, tudo teórico. Vou tentar deixar isso tudo mais concreto, mais palpável.

Vamos lá.

Pelas teorias modernas, a utilização do Direito Penal tem que ser mínima, ou seja, só devemos colocar o Direito Penal na “história” quando for realmente necessário.

Grosso modo, por essa concepção, o Direito Penal tem que agir MINIMAMENTE, ou seja, nem sempre caberá atuação do Direito Penal. Essa teoria é chamada de **concepção mínima** de Direito Penal.

Dessa concepção decorrem vários princípios: lesividade, insignificância, adequação social, intervenção mínima, fragmentariedade, subsidiariedade, proporcionalidade, proteção deficiente, culpabilidade.

Muitos princípios né?

Então vamos entender isso sem muito sofrimento. Acompanhe essa linha de raciocínio, vamos nela expor, de modo exemplificativo, todos esses princípios.

I – PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA OFENSIVIDADE

A ideia de insignificância penal centra-se no conceito MATERIAL de crime.

Grosso modo, devemos entender que um crime deve ter uma FORMA, que é aquilo que está ESCRITO na Lei Penal, é o conceito FORMAL do crime. É um conceito frio e legalista.

Por outro lado, o crime também deve ter um caráter MATERIAL, ou seja, UMA CONSEQUÊNCIA NO MUNDO MATERIAL, NO MUNDO REAL.

Não basta violar o que está ESCRITO na lei (Crime Formal), a conduta deve ter SIGNIFICANTE consequência no mundo material (Crime Material).

Assim, o Judiciário vem entendendo, que em alguns casos, a lesão ao bem jurídico protegido (tutelado) é tão pequena, tão INSIGNIFICANTE, **que não haverá crime, que não haverá TIPICIDADE MATERIAL**, por mais que haja **tipicidade formal** (o fato se encaixe perfeitamente ao tipo penal).

Exemplificando: a mãe que furta um litro de leite do supermercado para dar ao filho. Ela realmente cometeu formalmente um furto, ou seja, a conduta dessa mãe é perfeitamente enquadrada no tipo penal do furto. Entretanto, a lesão ao bem jurídico é tão pequena, tão insignificante, que não haverá crime, pois entende-se que não houve lesão ao bem tutelado (não lesão ao patrimônio), não houve tipicidade material.

Para se aferir a insignificância de uma conduta, em tese delituosa, a análise do fato **NÃO** limita-se ao aspecto patrimonial, devendo o aplicador do direito levar em consideração outros elementos, veja a decisão do STF:

Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público. (Processo: HC 84412 SP; Relator(a): CELSO DE MELLO; 19/10/2004)

Esse tipo de crime, que se aplica o princípio da insignificância, também recebe o nome de crime de bagatela, ou infração bagatelar. Ora, algum vendedor já falou para você que o preço do produto dele é uma BAGATELA, então, na verdade, ele estava querendo dizer que o preço é BAIXO, INSIGNIFICANTE. Lembre disso.

Observe bem o que consta no julgado do STF, a necessidade de **mínima ofensividade da conduta do agente**. Trata-se da aplicação também do **PRINCÍPIO DA OFENSIVIDADE ou LESIVIDADE**. Veja o que a Cespe já falou sobre esse princípio:

O Princípio da Ofensividade, ou Lesividade desenvolve que só estaremos diante de um crime quando a conduta expuser a perigo de lesão o bem jurídico penalmente tutelado. Se a conduta não provocar dano, não haverá perturbação da paz social. Dai o porquê o ordenamento jurídico penal moderno exigir perigo concreto oriundo da conduta realizada. Sem a afetação de um bem jurídico não há porque criminaliza-la. No Direito Penal moderno não há lugar para crimes de perigo abstrato. Entendimento diverso desaguará em um Direito Penal deveras intervencionista.

II – PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL

Qual o motivo de um lutador de boxe não responder criminalmente por Lesão Corporal? Qual o motivo de uma mãe não responder criminalmente por furar a orelha da filha? Qual o motivo de não responder por lesão corporal o profissional que coloca um *piercing* em parte de seu corpo, ou, ainda, faz-lhe uma tatuagem?

A resposta está no **Princípio da Adequação Social**.

A ideia é a seguinte, algumas condutas são aceitas pela sociedade, são consideradas socialmente adequadas, ainda que formalmente se enquadrem em um crime.

Tais lesões são consideradas justas e aceitas pela sociedade, **motivo pelo qual não há crime**, ou seja, **é uma causa de exclusão da tipicidade**.

No entanto, conforme entendimento do STJ, o princípio da adequação social **não** justificaria o arquivamento de inquérito policial instaurado em razão da venda de CDs e DVDs. Trata-se de fato típico:

Súmula 502 do STJ *Presentes a materialidade e a autoria, afigura-se típica, em relação ao crime previsto no artigo 184, parágrafo 2º, do Código Penal, a conduta de expor à venda CDs e DVDs piratas.*

III - PRINCÍPIOS DA INTERVENÇÃO MÍNIMA, DA FRAGMENTARIEDADE E DA SUBSIDIARIEDADE

Pelo princípio da INTERVENÇÃO MÍNIMA o Direito Penal só poderá INTERVIR se for para defender bens realmente importantes e caso não haja outro meio. Ele se divide em dois princípios: fragmentariedade e subsidiariedade.

O princípio da fragmentariedade é dirigido ao legislador penal, ou seja, a quem vai criar os crimes.

Pensem assim: *o que a lei pode considerar crime? Qualquer tipo de conduta? A lei poderia considerar crime “usar boné”?*

Não. De TODAS as condutas existentes, só **PARTE DAS CONDUCTAS** podem ser consideradas crimes. SÓ **FRAGMENTOS** DE TODAS AS CONDUCTAS podem ser consideradas crimes.

Só as condutas mais gravosas, perigosas, reprováveis, intoleráveis.

Em outras palavras, o Direito Penal não se preocupa com todas as condutas sociais, só com **ALGUMAS** condutas, só com **FRAGMENTOS DAS CONDUCTAS**, só com as condutas reprováveis.

Como visto, pelo princípio da fragmentariedade o Direito Penal **não se preocupa com todas as condutas sociais, só com ALGUMAS condutas, só com FRAGMENTOS DAS CONDUCTAS**, só com as condutas reprováveis.

Além disso, na resolução de desavenças e lides surgidas na comunidade, o legislador deve basear-se, **POR ÚLTIMO (e não primeiramente)**, na lei penal. É o princípio da SUBSIDIARIEDADE, ou seja, o **direito penal só vai agir em ultimo caso (ultima ratio)**.

Para resolver as desavenças na comunidade, o legislador deve primeiro utilizar a lei civil, a lei administrativa, a lei trabalhista, a lei tributária, caso essas leis não resolvam, o legislador deverá usar a *ultima ratio - a lei penal*.

Ressalta-se que em muitas questões há uma descrição do princípio da subsidiariedade, pedindo, porém, o princípio mais genérico, o da intervenção mínima. Se tiver a alternativa mais específica (subsidiariedade), marque ela, do contrário, não tenha medo de marcar intervenção mínima.

IV - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, DA CULPABILIDADE E DA PROIBIÇÃO DA PROTEÇÃO DEFICIENTE

Grosso modo, pelo **princípio da proporcionalidade** a lei deveria ser PROPORCIONAL, a lei penal deveria punir cada crime de acordo com sua “gravidade”.

Ora, aplicar a pena de morte indistintamente a todos os criminosos é punir de forma desproporcional. Em outras termos, é desproporcional punir um “ladrão” e um “assassino” com a mesma pena.

É isso que diz o enunciado.

Pela proporcionalidade deve-se verificar a compatibilidade entre os meios empregados pelo elaborador da norma e os fins que busca atingir.

Ora, não é proporcional punir com pena de morte alguém que furtou um bem, por exemplo. Não é compatível o meio empregado (pena de morte) com o fim que busca atingir (punir um “ladrão”).

Ensina Damásio de Jesus (Código Penal Anotado) sobre o **princípio da culpabilidade**: *“nullum crimen sine culpa. A pena só pode ser imposta a quem, agindo com dolo ou culpa, e merecendo juízo de reprovação, cometeu um fato típico e antijurídico”*.

Em outros termos, só responderá por um crime quem for CULPADO por ele. “Culpado” no sentido comum da palavra, naquele que todo mundo usa, ou seja, *“sou culpado pelo crime ter ocorrido”*. Alguém pode ser “culpado” pela ocorrência de um crime porque quis cometer o crime (teve DOLO) ou porque agiu com negligência, imperícia ou imprudente (CULPA EM SENTIDO ESTRITO).

Veja o que a Cespe já falou sobre Culpabilidade:

Culpabilidade é um Juízo de reprovação incidente sobre o autor de um crime, para a incidência da pena, avaliando sua capacidade de se pautar de conformidade com a norma, portanto não é uma qualidade da ação e sim uma avaliação da capacidade concreta daquele de que a pratica de agir de conformidade com o direito.

Uma das vertentes do **princípio da proporcionalidade é a proibição de proteção deficiente**.

A lei penal deve ser protegida de forma eficiente, assim, busca-se impedir um direito fundamental de ser deficientemente protegido, seja mediante a eliminação de figuras típicas, seja pela cominação de penas inferiores à importância exigida pelo bem que se quer proteger.

Vou apresentar um caso concreto, real e atual.

O Código Penal prevê que o crime de estupro que resulta em lesão corporal grave ou morte seja processado mediante ação penal condicionada à representação do ofendido (sucessores).

Veja bem, o Procurador Geral da República ajuizou a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4103 atacando tal regra, em outros argumentos, alega ofensa ao princípio da proibição de proteção deficiente. Em suma, alega que crime tão grave deveria ser incondicionado, de modo que hoje a proteção está deficiente. A questão ainda não foi julgada pelo STF.

Essa foi uma visão geral dos princípios modernos de Direito Penal.

É um assunto em construção.

Princípios Modernos de Direito Penal

Princípio	Detalhamento
Insignificância	Se lesão insignificante, não há crime (furto de 1 L de leite)
Ofensividade	Deve haver perigo concreto
Adequação social	Lesão aceita socialmente: não há crime (soco no boxe)
Intervenção mínima	Só intervém para bens importantes, se não há outro meio
Fragmentariedade	Legislador só cuida das condutas mais gravosas
Subsidiariedade	Direito penal é o último a ser adotado
Proporcionalidade	Punição proporcional à gravidade (furto não pode resultar em pena de morte)
Culpabilidade	Só responde quem tiver dolo ou culpa
Proibição da proteção deficiente	Bem fundamental deve ser protegido de forma eficiente

Faça os exercícios, eles te darão a noção de como serão pedidos, além de eventuais entendimentos jurisprudenciais. Saudações.

Professor RAFAEL ALBINO

Essa PALAVRA vale mais que sua aprovação:

“Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus.” Romanos 3:23

“Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados” Atos 3:19

"Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna". João 3:16

“Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo.” Romanos 10:9

Resumo

PRINCÍPIOS MODERNOS DE DIREITO PENAL

I – PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA OFENSIVIDADE

INSIGNIFICÂNCIA: O Judiciário vem entendendo, que em alguns casos, a lesão ao bem jurídico protegido (tutelado) é tão pequena, tão INSIGNIFICANTE, **que não haverá crime, que não haverá TIPICIDADE MATERIAL**, por mais que haja **tipicidade formal** (o fato se encaixe perfeitamente ao tipo penal).

Para se aferir a insignificância de uma conduta, em tese delituosa, a análise do fato **NÃO** limita-se ao aspecto patrimonial, devendo o aplicador do direito levar em consideração outros elementos, veja a decisão do STF:

Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público. (Processo: HC 84412 SP; Relator(a): CELSO DE MELLO; 19/10/2004)

PRINCÍPIO DA OFENSIVIDADE ou LESIVIDADE- veja o que a Cespe já falou sobre esse princípio:

O Princípio da Ofensividade, ou Lesividade desenvolve que só estaremos diante de um crime quando a conduta expuser a perigo de lesão o bem jurídico penalmente tutelado. Se a conduta não provocar dano, não haverá perturbação da paz social.

II – PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL

Algumas condutas são aceitas pela sociedade, são consideradas socialmente adequadas, ainda que formalmente se enquadrem em um crime, sendo consideradas justas e aceitas pela sociedade, **motivo pelo qual não há crime**, ou seja, **é uma causa de exclusão da tipicidade**. Exemplo: boxe, furar orelha.

III - PRINCÍPIOS DA INTERVENÇÃO MÍNIMA, DA FRAGMENTARIEDADE E DA SUBSIDIARIEDADE

Pelo princípio da INTERVENÇÃO MÍNIMA o Direito Penal só poderá INTERVIR se for para defender bens realmente importantes e caso não haja outro meio. Ele se divide em dois princípios: fragmentariedade e subsidiariedade.

Pelo princípio da fragmentariedade o Direito Penal **não se preocupa com todas as condutas sociais, só com ALGUMAS condutas, só com FRAGMENTOS DAS CONDUTAS**, só com as condutas reprováveis.

Além disso, na resolução de desavenças e lides surgidas na comunidade, o legislador deve basear-se, **POR ÚLTIMO (e não primeiramente)**, na lei penal. É o princípio da **SUBSIDIARIEDADE**, ou seja, o **direito penal só vai agir em ultimo caso (ultima ratio)**.

IV - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, DA CULPABILIDADE E DA PROIBIÇÃO DA PROTEÇÃO DEFICIENTE

Grosso modo, pelo **princípio da proporcionalidade** a lei deveria ser PROPORCIONAL, a lei penal deveria punir cada crime de acordo com sua “gravidade”. Pela proporcionalidade deve-se verificar a compatibilidade entre os meios empregados pelo elaborador da norma e os fins que busca atingir.

Ensina Damásio de Jesus (Código Penal Anotado) sobre o **princípio da culpabilidade**: “*nullum crimen sine culpa. A pena só pode ser imposta a quem, agindo com dolo ou culpa, e merecendo juízo de reprovação, cometeu um fato típico e antijurídico*”.

Uma das vertentes do **princípio da proporcionalidade é a proibição de proteção deficiente**. A lei penal deve ser protegida de forma eficiente, assim, busca-se impedir um direito fundamental de ser deficientemente protegido, seja mediante a eliminação de figuras típicas, seja pela cominação de penas inferiores à importância exigida pelo bem que se quer proteger.

Saudações.

Professor RAFAEL ALBINO

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
